

第5節 共犯の諸問題

刑法
No176

H22-5

(配点: 3)

月 日
月 日

次の【事例】に引き続く甲の行為に関する下記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、甲に（ ）内の犯罪が成立する場合には1を、成立しない場合には2を選びなさい。

【事例】

甲は、人通りの少ない道路を通行中、知人の乙が見知らぬ丙を「金を出せ。」と言いながらロープで縛り上げ、丙を道路脇の草むらの中に連れ込むのを偶然目撃した。

【記述】

ア. 甲が、草むらをのぞくと、乙が丙の上着のポケットを探って所持金を奪おうとしていた。

甲は、後で乙から口止め料をもらおうと考え、あえて何もせずにその場から立ち去った。乙

は、甲にのぞかれたことに気付かないまま、丙の所持金を奪った。(強盗罪の従犯)

イ. 甲が、乙が立ち去ったのを見届けてから草むらの中に入ったところ、丙が縛られたままだったので、甲は、丙が身に付けていた腕時計を奪った。(強盗罪の共同正犯)

ウ. 甲は、警察官が近付いてきたので、そのことを乙に知らせるために草むらに行ったところ、丙から奪った現金を着衣のポケットにしまった乙が、草むらから出ようとしていた。甲が乙を草むら内に押し戻して警察官をやり過ごしたため、乙の犯行はその場で発覚せずに済んだ。(強盗罪の従犯)

エ. 甲は、草むらの中に入り、同所で、丙の所持金を奪って山分けすることを乙と合意した。その上で、乙が緩んでいたロープをきつく縛り直した後、甲は、丙の所持金をその上着のポケットから奪った。(強盗罪の共同正犯)

オ. 甲が、草むらをのぞくと、乙が丙の上着のポケットを探って所持金を奪おうとしていた。甲が、乙に気付かれることなく草むらから道路に戻ろうとしたところ、付近住民の丁が、野草摘みのため草むらに入ろうとしていた。甲が、後で乙から分け前を得るため、丁に「スズメバチの巣があるから危ない。」と嘘を言って丁を追いつめたため、その間に乙は丙の所持金を奪うことができた。(強盗罪の従犯)

№176	従犯と共同正犯の成否						正答率
H22-5	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 1	オ 1	46%

ア 成立しない

判例は、不作為による幫助犯は、他人の犯罪行為を認識しながら法律上の義務に違背して自己の不作為によってその実行を容易ならしめることによって成立するとしており、行為者が犯罪を阻止すべき作為義務を負っていることを要求している（大判昭3.3.9）。本記述において、甲は、偶然に知人たる乙の行為を目撃したにすぎない者であるから、いずれの見解によっても、甲に結果発生を防止すべき作為義務は認められない。したがって、甲に強盗罪の従犯は成立しない。

イ 成立しない

判例は、「共同正犯として問擬するには……行為者相互の間に意思の連絡」が必要であるとしており、その理由として、判例は、共同正犯における一部実行全部責任の根拠が、行為者相互間に意思の連絡（共同犯行の認識）があり、互いに他の一方の行為を利用し、全員協力して犯罪事実を発生させることにあるということを挙げている（大判大11.2.25）。本記述では、甲と乙には何ら意思の連絡がないから、甲に強盗罪の共同正犯が成立する余地はない。したがって、甲に強盗罪の共同正犯は成立しない。

ウ 成立しない ★

判例は、従犯は実行行為に属せざる行為を以て正犯の実行行為を幫助するに依り成立するとしており（大判昭15.5.9）、継続犯を除き、正犯の犯罪が既遂に達した後に犯罪に関与した者については、「正犯の実行行為を幫助する」ことはできないから、幫助犯の成立する余地はないとしている。本記述では、乙を草むら内に押し戻して警察官をやり過ごした甲の行為は、乙の強盗罪（状態犯）が既遂に達した後に行われたのであるから、乙の「実行行為を幫助」したとはいえない。したがって、甲に強盗罪の従犯は成立しない。

エ 成立する

判例は、共同正犯の成立には、行為者間に意思の連絡があれば足り、暴行が共同者の予謀に基づくことを要しないとしており（大判大3.7.14）、共謀は実行行為の時点で成立していればよいとされている（現場共謀）。本記述では、甲は、所持金の山分けを乙と合意し、その後に乙がロープをきつく縛り直した上、丙の所持金を奪っているのであるから、現場共謀の成立後、暴行により丙の反抗を抑圧して財物を奪取したと評価することができる。したがって、甲に強盗罪の共同正犯が成立する。

オ 成立する

判例は、従犯成立の主観的要件としては、従犯者において正犯者の行為を認識しこれを幫助する意思があることをもって足り、従犯者と正犯者との間に相互の意思連絡があることは必要でなく、正犯者が従犯者の幫助行為を認識する必要はないとしている（大判大14.1.22）。本記述では、甲は、丁を追い払うことによって、乙の強盗行為を物理的に容易にさせたのであるから、強盗罪の従犯が成立する。したがって、甲に強盗罪の従犯が成立する。